

1000057-07.2022.8.26.0559

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gonçalves da Cunha Júnior

Comarca: Monte Aprazível

Foro: Foro de Monte Aprazível

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... pelos tribunais pátrios:

"Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2o, da Lei nº 11.343/06, 'contrario sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Monte Aprazível

Foro de Monte Aprazível

2ª Vara

Rua Monteiro Lobato, nº 269, Monte Aprazível - SP - cep 15150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1000057-07.2022.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000057-07.2022.8.26.0559

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Carlos Henrique Alves de Oliveira

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gonçalves da Cunha Júnior

Vistos.

CARLOS HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006, porque no dia 24 de junho de 2022, por volta das 15h15min., no Km 481 da Rodovia SP 310 (Rodovia Feliciano Sales Cunha), no município de Poloni, nesta comarca, transportava e trazia consigo 112,750kg de cannabis sativa L, droga vulgarmente conhecida como maconha, o fazendo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com intuito de fornecer ou entregar as substâncias ilícitas ao consumo de terceiros.

A denúncia teve por base o inquérito policial e, após defesa preliminar (fls. 175/186), foi recebida no dia 16 de agosto de 2022 (fls. 201/204).

O réu foi citado (fls. 218).

Ao longo da instrução, foram ouvidas as testemunhas tempestivamente arroladas e o réu foi interrogado (fls. 247/252).

Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia, por considerar provadas autoria e materialidade. A defesa, por sua vez, sustentou a aplicabilidade ao caso da causa de diminuição de pena veiculada no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Pediu, ainda, a fixação de regime inicial aberto para cumprimento da pena.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

Processo em ordem, que se desenvolveu sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa. Não há nulidade a ser declarada ou vício a ser sanado.

À mingua de preliminares de ordem processual, passo diretamente ao exame do mérito da causa, constatando que a materialidade delitiva foi demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 23/24), laudo de constatação (fls. 21/22), bem como pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 124/129).

A autoria é certa e indubitosa.

Ouvido em juízo (fls. 252), o policial rodoviário militar Everton Aparecido Pereira dos Santos relatou que fazia patrulhamento na rodovia SP 310, juntamente com o parceiro, no dia dos fatos. Quando a viatura se aproximou de um veículo GM Meriva, cor branca, perceberam que o condutor se assustou. Por duas vezes, ele chegou a derivar o veículo para o acostamento. Promoveram a abordagem, solicitaram a documentação e sentiram forte odor de maconha. Pediram que o condutor descesse e fizeram busca pessoal e veicular. Acharam, então, um compartimento falso no painel com muitas porções de maconha. Havia também um compartimento no para-choque traseiro com droga. O condutor disse que foi contratado por pessoa não revelada para levar o carro de Pereira Barreto a Monte Aprazível. Receberia R\$ 1.000,00 pelo serviço. O veículo estava adaptado ao transporte de entorpecente. É policial há doze anos e a apreensão foi de grande porte, considerada a experiência diária.

A testemunha Leandro Silvestre Pereira de Souza (fls. 252), também policial rodoviário militar, confirmou integralmente o depoimento prestado por seu companheiro de ofício, enfatizando que o odor de maconha que o carro emanava era muito acentuado, facilmente perceptível por quem dele se aproximasse.

Por fim, em seu interrogatório (fls. 252), o acusado confirmou que transportava o entorpecente ciente de sua existência, bem como que receberia R\$ 1.000,00 pelo serviço. Anotou que, originalmente, pensava que apenas levaria um veículo de um local para outro. Chegando em Pereira Barreto, entretanto, soube que o transporte envolvia tóxico. Referiu tentativa de desistência, não aceita, entretanto, por seu acompanhante.

Não há dúvidas, destarte, de que o réu fora efetivamente surpreendido transportando entorpecente, conduta que se amolda ao tipo imputado.

É evidente que, pela enorme quantidade, não se cogita de propósito outro, que não o mercantil, à luz dos critérios elencados no artigo 28, § 2º, da Lei de Drogas, de maneira que a situação do flagrante descortinou inequívoca prática de tráfico.

Calha obter-se que a busca veicular que desaguou na apreensão da droga não padeceu de qualquer vício, entrevendo-se clara fundada suspeita na peculiaridade de o veículo do réu, parado para averiguação de trânsito em decorrência de condução irregular, emanar forte cheiro de entorpecente, facilmente perceptível do lado de fora do auto, afirmação absolutamente plausível, frente ao volume de maconha carregado.

Insuficientes as declarações do agente, noutro giro, para se deduzir a adesão à empreitada ilícita por coação física ou moral, quer porque não coligido nenhum elemento de convicção concreto acerca do contexto narrado, quer porque as descrições do contratante do transporte e do indivíduo que o teria levado até a cidade de Pereira Barreto foram demasiadamente genéricas e imprecisas, a inviabilizar eventual identificação e investigação.

De todo modo, se entender pertinente, poderá o Ministério Público solicitar a extração das cópias necessárias para eventual tentativa de apuração dos comparsas.

O fato de não ter sido o increpado flagrado efetuando, propriamente, a comercialização de entorpecente não compromete a materialização do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Como se sabe, o tipo penal em análise constitui delito de ação múltipla ou conteúdo variado, perfazendo-se com a realização de qualquer dos verbos nele descrito, os quais não se encontram submetidos a regime cumulativo.

Atente-se para o quanto já decidido pelos tribunais pátrios:

"Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do

tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente."(RT 584/347).

Na hipótese, consoante já exaustivamente explanado, o acusado transportava enorme quantidade de substância ilícita, evidenciando o contexto que o tóxico seria entregue ao consumo de terceiros.

No que toca à tese defensiva principal, o réu não faz jus à diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, porque as especificidades da empreitada ilícita escancaram que ele, indubitavelmente, atuou no caso como parte integrante de organização criminosa, o que, no contexto normativo aplicável, dispensa demonstração de reiteração, ex vi do disposto no artigo 35, da Lei 11.343/06, alusão feita apenas para fixação de parâmetro, já que tal imputação não consta na peça acusatória.

Entrementes, o laudo de fls. 130/140, corroborando a fala das testemunhas policiais, dá conta de que o veículo utilizado tinha mesmo adaptações para o transporte de entorpecente, evidenciando que foi adrede preparado para a tarefa, a revelar planejamento e coordenação, traços marcantes de organização.

Ainda, o réu reportou contato com no mínimo outros dois agentes, um que atribuiu o trabalho e outro que o levou até o local em que estava o veículo, nuance que descortina clara divisão de tarefas, outro traço marcante de organização.

A elevadíssima quantidade de entorpecente autoriza a inferência de poder econômico, marca flagrante de organização.

Por fim, o recebimento, para transporte, de material presumidamente valioso denota que o denunciado, no mínimo, contava com a confiança do agente que lhe encomendou o trabalho.

Nessa moldura, mesmo não havendo evidências de que o réu tenha praticado outras ações similares, em conjunto ou não com os mesmos possíveis comparsas, não há dúvidas de que ele, no caso concreto em análise, com ou sem poder de decisão dentro da estrutura ilícita, atuou como braço de organização criminosa, conclusão não afastada pelas vestes que usava no momento da abordagem, pela presença ou não de tatuagens em sua pele ou mesmo por sua origem social.

Não se está aqui simplesmente conjecturando, impende obtemperar. Está-se apenas extraindo conclusão lógica de circunstâncias conhecidas e provadas que, relacionadas ao fato, por indução, autorizam a inferência da existência de outras circunstâncias (artigo 239, do Código de Processo Penal).

Pertinente a citação do escólio de Guilherme de Souza Nucci sobre o referido artigo 239, do Código de Processo Penal:

"(...) os indícios são perfeitos tanto para sustentar a condenação, quanto para a absolvição. Há autorização legal para a sua utilização e não se pode descurar que há muito preconceito contra essa espécie de prova, embora seja absolutamente imprescindível ao Juiz utilizá-la. Nem tudo se prova diretamente, pois há crimes camuflados – a grande maioria – que exigem a captação de indícios para a busca da verdade real" (Código de Processo Penal Comentado. 12. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 555).

Relevante ponderar que o C. STJ, em julgado recentíssimo, mutatis mutandis, seguiu o mesmo raciocínio, in verbis (grifei):

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO NO DOBRO DO MÍNIMO LEGAL. QUANTUM DEVIDAMENTE MOTIVADO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA ESPECIALMENTE NOCIVA. SEGUNDA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Cabe às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios aplicados pelas instâncias ordinárias no cálculo das penas, visando evitar eventuais arbitrariedades, por inobservância dos parâmetros legais ou do entendimento jurisprudencial firmado. Diante disso, salvo excepcional flagrante ilegalidade, o reexame da presença de circunstâncias judiciais e da existência dos elementos concretos utilizados para a individualização da pena evidenciam-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento de matéria

fático-probatória. 2. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível até mesmo que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015). 3. Na hipótese, a pena-base foi exasperada em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada tanto pela sofisticação do delito que se valeu de uma aeronave para o transporte das drogas, assim como de equipamento de comunicação de alta tecnologia e de uma fazenda isolada, quanto pela exorbitante quantidade e natureza especialmente letal da droga apreendida - 469 kg de cocaína - o que está em consonância com o disposto no art. 42, da Lei n. 11.343/06 e com a jurisprudência firmada nesta Corte acerca do tema. Precedentes desta Corte referendando a majoração da pena-base no dobro: AgRg no REsp n. 1.920.043/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021; (AgRg no HC n. 446.455/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/2/2020, DJe de 20/2/2020; AgRg no HC n. 664.488/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021; REsp 2.004.413/SP, Relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região), DJe de 02/08/2022; HC 749.693/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJe de 21/06/2022; AREsp 1.997.081/MS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 14/06/2022; HC 744.340/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 31/05/2022. 4. Tampouco há como se dar guarida à alegação da defesa de que os aspectos sopesados pelo magistrado de primeiro grau para valorar negativamente as circunstâncias do crime - (I) uso de aeronave, (II) equipamentos de ponta para comunicação e (III) utilização de uma fazenda isolada - corresponderiam, na realidade, a indicativos da transnacionalidade do delito que justificariam unicamente a majoração da pena com base no art. 40, I, da Lei de Drogas. Isso porque a majoração prevista no art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006 somente demanda a constatação da transnacionalidade do tráfico, seja dizer, do transporte e da origem internacional da droga. Ora, tal transporte pode ser levado a cabo por diversos meios bem menos sofisticados como automóveis, caminhões, motocicletas, bicicletas e mesmo a pé. Assim sendo, a sofisticação da operação engendrada para concretizar a empreitada criminosa justifica, sim, o aumento da pena-base em virtude das diferenciadas circunstâncias do crime. 5. A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. 6. No caso, a instância a quo concluiu ser incabível o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 diante da consciência do réu de que compunha a organização criminosa, realizando o transporte de entorpecentes pelo valor de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais). Ademais, a descrição do modus operandi da organização revela um elevado nível de sofisticação, destinado a operar com grande quantidade de droga de grande valor (quase meia tonelada de cocaína), empreitada que não se coaduna com a participação de pequeno traficante sem qualquer tipo de vínculo com a organização criminosa. 7. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 748.401/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.).

Assim, afastadas as teses defensivas, comprovadas autoria e materialidade e não incidindo causa excludente da ilicitude ou culpabilidade, de rigor a condenação do acusado nas sanções contidas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo, pois, a dosar a pena, considerando o critério trifásico trazido pelo artigo 68, do Código Penal.

Para fixação da pena-base, devem ser levadas em consideração as circunstâncias judiciais, tanto as genéricas, veiculadas pelo artigo 59, do Código Penal, como as específicas para o delito em análise, insculpidas no artigo 42, da Lei de Tóxicos. Nesse mister, não obstante primário (fls. 198/200), o réu foi surpreendido transportando enorme quantidade de entorpecente, praticamente 113kg, o suficiente para alimentar a compulsão de número incalculável de usuários, nuance que imprime,

concretamente, elevado grau de censurabilidade à conduta perpetrada. Desse modo, pela quantidade da droga, fixo a pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Pela confissão espontânea (artigo 65, III, "d", do Código Penal), diminuo a pena em 1/6 (um sexto), chegando ao montante de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Não incidem outras atenuantes ou agravantes.

Não incidindo causa de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena até aqui calculada.

Inexistindo nos autos elementos que forneçam parâmetros seguros para a aferição da condição econômica do réu, fica o valor do dia-multa fixado no mínimo legal, qual seja, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, nos termos do artigo 43 da Lei 11.343/2006.

A despeito do posicionamento recentemente adotado pelo C. STF (habeas corpus nº 97.256/RS, cujos efeitos foram ampliados pela Resolução nº 5/2012, do Senado Federal), o quantum final da pena corporal inviabiliza a aplicação dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Em observância ao entendimento esposado pelo plenário do C. Supremo Tribunal Federal no julgamento dos habeas corpus n.º 111.840 (Rel. Min. Ministro Dias Toffoli, j. 27.6.2012) e 118.533/MS (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/06/2016), registro que o regime aplicável em função do artigo 33, do Código Penal, seria o semiaberto (pena superior a quatro anos e inferior a oito, aplicada a réu primário), o qual, reservado melhor juízo ao E. Tribunal, não se mostraria suficiente para a punição da conduta, de elevada gravidade concreta.

Aqui, releva repisar que o réu foi surpreendido transportando 112,750kg de entorpecente, o suficiente, reitere-se, para alimentar a fissura de numero indeterminado de pessoas.

Referida conduta, legalmente definida como hedionda, desencadeia catastróficas consequências sociais, já que a disseminação das drogas, além de representar grande prejuízo individual ao consumidor, dá ensejo, inegavelmente, à ocorrência de diversos outros crimes, especialmente os patrimoniais.

Não se revela exagerado afirmar que o traficante, buscando lucro, explora a degradação humana, aproveitando-se da compulsão do usuário que, como sabido, não mede esforços para suprir a necessidade de acesso ao "produto" oferecido.

O "freguês", destarte, é presa fácil para o mercador do tóxico, resultando dessa desigual e injusta interação problemas de saúde e segurança públicas de dimensões incomensuráveis.

Nesse cenário, a ação perpetrada, diante de sua gravidade concreta, merece resposta penal condizente, de maneira que a fixação de regime inicial semiaberto geraria na comunidade grande sensação de insegurança, além de criar no próprio réu sentimento de impunidade, que o estimularia a prosseguir violando a lei penal.

À luz, assim, das circunstâncias judiciais especiais desfavoráveis, que, em referência à súmula 440, do C. STJ, ensejou a majoração da pena-base, o regime inicial será o fechado.

Destaco, encerrando, que a regra constante da nova redação do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, não conduzirá à alteração do regime inicial de cumprimento, fixado em função da gravidade concreta do crime e das circunstâncias judiciais especiais desfavoráveis, e não do montante da reprimenda corporal, cumprindo anotar que a regra em testilha não autoriza o juízo do conhecimento a realizar progressão de regime ou detração de pena, atribuições exclusivas do juízo das execuções (artigo 66, III, "b" e "c", da Lei 7.210/84).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia, fazendo-o para condenar CARLOS HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos (fls. 17), como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, ao cumprimento de pena de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

A multa deverá ser paga em 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado, nos

termos do artigo 50 do Código Penal, observada a disposição constante do artigo 49, § 2º, do mesmo Codex.

Não concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, porquanto, à luz da nova redação dada ao artigo 313, do Código de Processo Penal, pela Lei 12.403/2011, impõe-se a manutenção da prisão, ficando agora reiterados os fundamentos expostos na r. decisão de fls. 39/41, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Em acréscimo, não se pode ignorar que deverá o inculpado iniciar o cumprimento de sua pena corporal em regime fechado, de modo que a libertação neste momento processual comprometeria a aplicação da Lei Penal.

A ponderação supra serve como revisão periódica da necessidade de manutenção da prisão preventiva, ex vi do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido. Caso haja recurso de qualquer das partes, expeça-se guia de recolhimento provisório, encaminhando-a ao Juízo das Execuções Criminais competente.

Caso tal providência ainda não tenha sido tomada, determino a destruição do entorpecente apreendido, na forma do artigo 50, §§ 3º, 4º e 5º, da Lei 11.343/06. Com fundamento na inteligência do artigo 91, II, "a", do Código Penal, tratando-se de inequívoco instrumento do crime (veja-se que o veículo continha adaptações próprias para transporte da droga), sem notícia de que tenha sido obtido por meio criminoso, em prejuízo de vítima certa, decreto a perda em favor da União do veículo apreendido nos autos (vide fls. 23), o qual deverá ser vendido pela SENAD, nos termos do artigo 63, § 2º, da mesma Lei.

Não incidem os efeitos da condenação previstos no artigo 92, do Código Penal, dada a natureza da infração penal praticada.

Deixo de adotar a providência determinada pelo artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, porque o delito praticado não possui vítima certa.

Custas na forma da Lei (artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual 11.608/03).

Após o trânsito em julgado, proceda-se na forma do artigo 63, § 4º, da Lei 11.343/06 e do Comunicado CG nº 805/2019, com relação aos bens e valores declarados perdidos em favor da União, oficie-se para suspensão dos direitos políticos dos acusados enquanto perdurarem os efeitos da condenação, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal e expeça-se o necessário para o cumprimento definitivo das penas impostas, realizando-se as anotações e comunicações de praxe, tudo de acordo com as NSCGJ (notadamente com os artigos 393 a 400, do capítulo IV, seção XI, subseção V, Tomo I; do artigo 468, do capítulo IV, seção XX, subseção I, Tomo I; e do artigo 479, do capítulo IV, seção X, subseção III, Tomo I).

Caso haja habeas corpus informado nos autos sem comunicação de julgamento definitivo, oficie-se ao respectivo Tribunal noticiando a prolação de sentença, remetendo-se cópia.

P.R.I.C.

Monte Aprazível, 30 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA